

1501336-77.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... de Ygor com outros crimes, apenas com tráfico.

A testemunha Hector Nogueira Rodrigues, também policial militar, relatou que patrulhava o bairro Jardim Ivone, local onde há intenso tráfico de drogas. Avistou os réus e mais um indivíduo. Ygor entregou algo a este indivíduo, o qual dali se retirou rapidamente. Fez o retorno na mesma rua e os réus não perceberam a aproximação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501336-77.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501336-77.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2030452/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22783832 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 1241/22/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2030452 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 1241/22/050 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YGOR FELIPE GOMES IVANOVAS MATIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

YGOR FELIPE GOMES IVANOVAS MATIAS e ROBERT ALEXANDRE DOS SANTOS MIRANDA foram dados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 11h00, na rua Pedro Campos Silva, quadra 04, Jardim Samaritano, nesta cidade, traziam consigo, para fins de tráfico, 6,38 gramas de cocaína e 6,47 gramas de maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificados (fls. 122 e 124), os réus apresentaram a defesa preliminar de fls.

131/132.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 01 de abril de 2.022 (fls. 137/139). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 201 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 223/231).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 235/267, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- os réus não foram vistos vendendo drogas; 3)- na posse de Ygor, havia apenas quatro porções de maconha e quatro de cocaína, quantidades razoáveis para consumo próprio; 4)- no local, havia um terceiro indivíduo, cujo paradeiro é ignorado e que seria o traficante; 5)- embora os policiais tenham visto Ygor entregando algo a um terceiro, não os abordaram de imediato, preferindo dar a volta; 6)- quando retornaram, os policiais perderam os indivíduos de vista e aquele terceiro não estavam mais no local; 7)- não é crível que Robert, com quem não foram encontradas drogas, fosse afirmar aos policiais que estava vendendo-as e que o dinheiro era produto do comércio da noite anterior, ainda mais se se considerar que a abordagem se deu às 11:00 h; 8)- a confissão informal não é prova válida; 9)- os depoimentos dos policiais não são suficientes para a condenação; 10)- eventualmente, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; 11)- os réus fazem jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, ao regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 20/21 e pelo laudo pericial de fls. 121/124 (vinte porções de cocaína com peso de 6,38 gramas e oito porções de maconha com peso de 6,47 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos aos acusados.

Em juízo, a testemunha Cristiano Henrique dos Santos, policial militar, disse que o fato se deu no Jardim Ivone e tem grande incidência de tráfico. Em razão disso, o patrulhamento é comum naquela área. Passou por uma rua transversal e os réus foram avistados no meio da quadra da outra via pública em companhia de um terceiro indivíduo. Viu Ygor entregando algo a este indivíduo. Os policiais fizeram a volta e não foram vistos pelos acusados. Eles já estavam na esquina. Deu a ordem de parada e o acusado Ygor tentou se evadir, mas foi contido. Em revista pessoal, Ygor logo disse que havia "B0" em seu bolso. Na vestimenta, foram encontrados eppendorfs da cor rosa e maconha. Robert foi abordado por seu parceiro e, em poder dele, havia duzentos reais em dinheiro. Tem conhecimento de que os dois andam juntos e que Ygor gerencia a venda de entorpecentes. Eles estavam na troca de turno. Robert confessou que o dinheiro provinha da venda de entorpecente do dia anterior e que iria levá-lo para ser guardado na casa de uma tia. O patrulhamento no bairro é constante. Tinha informações de frequentadores e usuários de que Ygor exercia a gerência e que Robert recebia o dinheiro. Quando avistados, os réus estavam com outra pessoa, a quem Ygor entregava algo. Naquele momento, eles estavam de costas e não os conseguiu identificar. Quando os avistou, os três estavam parados. Estava a cerca de cem metros deles e não foi possível ver o que Ygor entregava. Os policiais se aproximaram e os indivíduos não viram. Ao chegarem perto, os três estavam perto da esquina e o terceiro indivíduo não estava mais ali, apenas os dois acusados caminhando. Quando Ygor estava entregando objeto ao terceiro, Robert estava na companhia dele. Na delegacia, Robert contou que viu os policiais entrarem no bairro quando estavam na rua debaixo e que, por isso, deram uma volta na quadra. Foi Roberto quem disse que o dinheiro era produto da venda de drogas do dia anterior. Como Ygor logo foi colocado no compartimento de presos da viatura, não sabe se ele admitiu a prática do tráfico. Os policiais conversaram com Robert. Somente notou

que a pessoa abordada era Ygor, conhecido da polícia, no momento da abordagem. Robert estava sempre no local com Ygor. Recentemente, Robert foi novamente visualizado ali, mas nada foi encontrado com ele. Robert não mora nas proximidades e disse que uma tia dele é quem reside nas imediações. Não tinha conhecimento do envolvimento de Ygor com outros crimes, apenas com tráfico.

A testemunha Hector Nogueira Rodrigues, também policial militar, relatou que patrulhava o bairro Jardim Ivone, local onde há intenso tráfico de drogas. Avistou os réus e mais um indivíduo. Ygor entregou algo a este indivíduo, o qual dali se retirou rapidamente. Fez o retorno na mesma rua e os réus não perceberam a aproximação da viatura. Ygor tentou fugir, mas foi abordado e logo confessou que tinha "BO" no bolso. Com Ygor, foram localizados cocaína, maconha e dinheiro. Já Robert possuía duzentos reais e confessou que o numerário provinha da venda de drogas. Via-os juntos. Os dois estavam caminhando juntos e o terceiro comprava droga de Ygor, ao lado do qual estava Robert. Em patrulhamento recente, viu Robert novamente no mesmo local. Eles confessaram a prática do tráfico. A cocaína estava embalada em eppendorfs, ao passo que a maconha estava em porções.

Interrogado em Juízo, o réu Ygor afirmou que estava sozinho na rua e viu Robert no meio da quadra. Possuía quatro pinos e quatro porções de maconha para seu consumo. Robert se aproximou. O traficante logo avistou a polícia e correu, jogando os pinos perto. Não correu porque nada devia. Esperou os policiais e logo os informou que possuía drogas para seu uso no bolso. Os policiais encontraram duzentos reais com Robert. Informou aos policiais que a droga encontrada mais à frente não era "nossa". Foi algemado, colocado na viatura e conduzido para o plantão policial. Não estava junto com Robert quando comprou a droga. Ele estava no meio da quadra. Chamou Robert para perguntar se iria descer a rua. Quando Robert se aproximou, o traficante que lhe vendeu a droga viu a polícia, correu, jogou a droga no chão e virou a esquina. Conhece Robert do bairro. A tia dele mora na mesma rua que familiares seus. Porém, não mantém vínculo de amizade.

Interrogado em Juízo, o réu Robert afirmou que havia acabado de sair de sua casa e, no meio do quarteirão, estavam "indo". Seu cachorro havia escapado. Quando chegaram na esquina, notou que a polícia estava atrás deles. Havia um outro moleque, que correu e jogou a droga para trás. Não trabalhava em biqueira. Não conseguiu arrumar testemunhas. Conhece Ygor da vila, onde sua mulher, mãe de seu filho, mora. Ele não vende drogas. Soube que Ygor foi comprar entorpecente para consumir. Morava na rua de cima. Estava caminhando. Iria levar o dinheiro para sua tia. Encontrou Ygor no meio do quarteirão e disse que iria levar o dinheiro e iria atrás de seu cachorro. Ygor lhe perguntou se iria para "lá". Confirmou que sim. Foram juntos. Ao chegar na esquina e olhar para trás, viu a polícia no encalço deles. Havia acabado de fazer 18 anos.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação dos acusados nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em suas defesas.

É certo que os réus, quando interrogados em juízo, negaram a prática do tráfico.

A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, os quais observaram que Ygor, na ocasião acompanhado de Robert, entregou algo a um terceiro. Ainda de acordo com os policiais, Ygor portava cocaína e maconha em porções prontas para venda e dinheiro, ao passo que Robert tinha consigo apenas dinheiro.

Não colhe o argumento de que os depoimentos dos policiais, quando isolados, não se prestam à condenação.

No aspecto considerado, é lícito perguntar: por qual razão dois servidores públicos iriam à polícia e depois viriam em juízo, a fim de relatar fatos inverídicos em detrimento de pessoas que sequer ou pouco conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e criminalmente pela falsa acusação?

Insista-se ainda que, como a própria defesa destacou, a abordagem se deu às 11:00 h.

Acresça-se que o fato data de 02/02/2022, uma quarta-feira, e ocorreu em plena via pública.

Os policiais, a quem se atribui a pecha de terem tirocínio tal para criar uma estória fantasiosa, por certo não seriam ao mesmo tempo tão tolos a ponto de cometer abuso de autoridade naqueles circunstâncias, por justamente saberem que poderiam ser flagrados por testemunhas ou mesmo filmados por câmeras de celulares. Ademais, as afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Prosseguindo, não merece guarida a alegação de causar estranheza a conduta dos policiais, de preferirem dar a volta com a viatura ao invés de realizarem a imediata abordagem, o que teria permitido com que o terceiro visualizado na cena do crime, verdadeiro traficante, pudesse ter se evadido.

Primeiro, não ficou bem esclarecido se a manobra dos policiais atrasou em alguma medida a chegada ao local do crime.

Veja-se que, segundo a testemunha Hector, os policiais fizeram a volta na mesma rua.

Sendo assim, não está descartado que sequer houvesse meio mais ágil de se aproximar dos réus sem que os policiais fossem desde logo notados por eles.

Quanto ao terceiro que estava na cena do crime e que depois não foi mais visto, não se pode considerá-lo como o verdadeiro traficante.

Veja-se que, segundo os policiais, Ygor entregou algo a tal indivíduo.

Poder-se-ia alegar que a entrega não versou sobre droga, e sim sobre dinheiro correspondente ao pagamento das porções de cocaína e maconha compradas por Ygor. No entanto, tal alternativa não tem como ser reputada verdadeira.

Afinal, em poder de Ygor, não foram encontradas tão somente quatro porções de maconha e quatro de cocaína, mas sim nada menos do que vinte pinos de cocaína e oito porções de maconha.

Outrossim, nenhum outro entorpecente foi achado pelos policiais no chão, onde teriam sido atiradas pelo terceiro indivíduo antes de se evadir.

Como se vê, os acusados faltaram com a verdade, e o fizeram com o nítido propósito de fazer a Justiça crer que Ygor trazia apenas quantidades ínfimas de entorpecentes, justamente por saberem que, somente assim, poderiam descaracterizar a traficância.

A falta com a verdade no interrogatório do acusado é elemento que pode e deve ser considerado pelo juiz na formação de sua convicção.

À propósito:

"Não se olvide que o parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal, adotando o princípio do nemo tenetur se detegere, previsto na Constituição Federal, determina que o silêncio do acusado não poderá ser considerado em seu desfavor em processo criminal; todavia, as inverdades pode ele proferidas em interrogatório judicial constituem-se em mais um elemento a ser considerado pelo Magistrado no momento da formação de sua convicção. Nesse sentido, ponderou o Eminentíssimo Desembargador José Raul Gavião de Almeida que ' ... Se o réu optar por falar, no

interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade' (TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Apelação n. 990.10.390742-6, voto n. 10.943)." (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Enfim, a circunstância de a narrativa dos réus ser contrária à verdade em ponto central da controvérsia permite formular convicção em desfavor deles.

Observe-se, mais, que, seja perante os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, seja perante a autoridade policial (fls. 10 e 11), os acusados nada disseram a respeito da presença daquele terceiro indivíduo que teriam vendido droga para Ygor e que depois se evadiu.

Ora, fosse verdadeira a narrativa por eles apresentada em juízo, o natural seria que, o mais rápido possível, informassem as autoridades a respeito da presença de um outro indivíduo que ali estava vendendo drogas e indicassem seu paradeiro.

Os policiais militares, contra quem nada de suspeito pesa, certamente não se furtariam a imediatamente diligenciar à cata do traficante.

Aliás, isso é o que comumente ocorre em diversas diligências realizadas pela Polícia Militar, cujos integrantes passam a patrulhar as imediações visando a busca do suspeito de um crime, após serem informados do possível local onde ele pode ser encontrado.

Nada obstante o respeito deste juízo a entendimento diverso, não causa espécie o fato de Robert, flagrado apenas na posse de dinheiro, ter admitido a traficância. É que, embora ele apenas tivesse numerário consigo, foi flagrado em circunstâncias bastante comprometedoras de seu envolvimento com o tráfico, quais sejam: na posse de dinheiro e na companhia de Ygor, que houvera acabado de ser visto pelos policiais entregando algo a um terceiro e que estava na posse de vinte pinos de cocaína e oito porções de maconha, embalados de forma própria ao comércio, em local conhecido como ponto de tráfico.

Ao contrário do que se alega, é natural que aquele que é surpreendido cometendo ilícito, no instante do flagrante, sem a frieza e calculismo próprios de um momento ulterior em que se tem tempo para maior reflexão utilitarista na busca de uma narrativa que possa livrá-lo da severa consequência criminal, acabe por admitir a prática criminosa.

Trata-se de dar vazão a um sentimento de penitência, que não se equipara a momento de puro racionalismo.

Prova disso é que não são raras situações em que agentes flagrados na via pública em posse de alguma quantidade de droga informem os policiais sobre a presença de mais entorpecente em outro local, e que confessam todas essas circunstâncias perante o juízo.

Lançam-se aqui tais ponderações não propriamente para sustentar a validade da confissão informal, que sequer está sendo levada em conta para embasar a condenação, mas tão somente para corroborar a lisura do procedimento dos policiais militares e a sinceridade de suas afirmações.

Destarte, os fatos descritos na denúncia e respectiva autoria estão bem demonstrados.

Por outro lado, não há dúvida de que os acusados estavam praticando o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso em tela, os réus, juntos, portavam drogas em quantidades mais do que suficientes para caracterização do comércio espúrio, a par de razoável quantia em dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico, tendo um deles sido visto entregando algo a um terceiro.

Logo, o fato deve ser enquadrado na moldura do artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006.

Nesse sentido:

"Portanto, para a correta tipificação da conduta, é fundamental que o Julgador

verifique as particularidades do delito, atentando-se à natureza e quantidade da droga, bem como ao local em que se desenvolveu a ação delitiva, às circunstâncias nas quais estava o agente. In casu, foram arrecadadas 3,60g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack", sendo certo que a aludida droga estava separada em vinte e uma porções, propícias ao comércio." (TJ-MG, Apelação Criminal 10481100114174001, Des. Rubens Gabriel Soares – Relator).

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, a condenação dos acusados pela prática do tráfico é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

Os réus não têm antecedentes criminais (fls. 50/51 e 53/54).

Diante disso, fixam-se as penas no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão para cada réu.

A atenuante da menoridade relativa não tem repercussão na redefinição do montante da reprimenda – já estabelecida no mínimo legal -, ante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Os réus fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

De início, consigne-se que somente lhes podem ser atribuídas quantidades de drogas que não são das mais elevadas, a par de duzentos e oitenta reais em dinheiro.

Assim, não é possível dizer que eles se dedicavam à atividade criminosa em função do montante de entorpecente e dinheiro apreendido.

A existência de registros de atos infracionais praticados por Ygor, igualmente, não impede o reconhecimento do privilégio.

Eventuais condenações na adolescência não devem redundar em empecilho ao benefício. Este juízo vinha deixando de aplicar o privilégio para réus com condenação por ato infracional, que indicasse dedicação a atividade criminosa, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e por entender ser necessário, a bem da segurança jurídica e do prestígio ao princípio da igualdade, seguir a orientação de Tribunais Superiores.

Ocorre, porém, que, o Supremo Tribunal Federal tem adotado entendimento em sentido contrário, ou seja, não é possível levar em conta prática de atos infracionais pretéritos para fins de afastamento da causa de diminuição.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas (arts. 1º e 112) e visam à proteção integral do adolescente infrator." (STF. Habeas Corpus 184.979/ES, j. em 08/05/2020.

Relatora Ministra Carmen Lúcia).

E, ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A NEGAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SE REFAZER A DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A prática anterior de atos infracionais pelo paciente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante

do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006." (STF. Ag. Reg. Em Habeas Corpus 191.992/SP, j. em 08/04/2021. Relator: Ministro Edson Fachin).

Nessa conformidade, não se poderia dizer que Ygor se dedica a atividades criminosas, apenas em razão de ostentar atos infracionais pretéritos.

Do contrário, haveria não somente ofensa ao princípio da inimizabilidade penal dos menores de dezoito anos, previsto no texto constitucional (art. 228 da CF), como também ao princípio da proteção integral de criança e do adolescente, dada sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (arts. 3º e 121 da Lei 8.069/90).

Não bastasse, a utilização dos registros de jovens infratores em processos posteriores, quando de sua fase adulta, é vedada pelo item 21.2 das Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça da Infância e Juventude (Regras de Pequim).

Em que pese se tratar de Resolução da Assembleia Geral da ONU e, portanto, instrumento não vinculante, impossível descartá-la enquanto orientação na aplicação do direito nacional.

Destarte, a partir da existência de registros de atos infracionais não se pode concluir que se está diante, aqui, de agente dedicado a atividades criminosas. Considerando, de resto, terem sido pequenas as quantidades de drogas e dinheiro encontradas em poder dos réus, reduz-se a pena na fração máxima de dois terços, resultando em um ano e oito meses e dez dias de reclusão, mais cento e noventa e quatro dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no Habeas Corpus n. 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou: "Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual os acusados começarão a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, pequenas quantidades de dinheiro e de droga), fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art.

5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar os acusados Ygor Felipe Gomes Ivanovas Matias e Robert Alexandre dos Santos Miranda como incursos nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, a cumprirem um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto aos telefones celulares apreendidos, são bens cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

Ante a pena imposta, expeça-se alvará de soltura com relação ao réu Ygor.

P.R.I.

Bauru, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA